

CAPÍTULO 46

INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Silvina S. González Napolitano

1. Concepto y principales instrumentos.....	976
2. Las fuentes del derecho internacional humanitario y la cláusula Martens	981
3. Principios del derecho internacional humanitario.....	981
4. La función del Comité Internacional de la Cruz Roja como promotor y guardián del derecho internacional humanitario.....	984
5. Los emblemas protectores reconocidos por el derecho internacional humanitario..	985

CAPÍTULO 47

DERECHO INTERNACIONAL PENAL

Romina E. Pezzot

1. Introducción	987
2. Noción de derecho internacional penal.....	987
3. Evolución histórica	989
4. Delitos y crímenes internacionales	992
4.1. Delitos internacionales	993
4.2. Crímenes internacionales.....	994
4.3. Terrorismo internacional.....	1000
5. El juzgamiento del individuo: las jurisdicciones estatales e internacionales	1002
5.1. La lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales y su influencia en la administración de justicia.....	1005

CAPÍTULO 48

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL

Agustín Leonardo Niebuhr

1. Introducción	1007
2. Extradición: concepto y principios aplicables	1007
3. Normativa argentina: Ley 24.767	1010
3.1. Ámbito de aplicación.....	1010
3.2. Condiciones para la extradición pasiva	1010
3.3. Improcedencia.....	1011
3.4. Procedimiento: principales características.....	1013
4. Extradición por crímenes internacionales	1015
4.1. Principios aplicables	1015
4.2. Jurisprudencia relevante	1017
4.2.1. Jurisprudencia argentina.....	1017
4.2.1.1. Caso <i>Bohne</i>	1017
4.2.1.2. Caso <i>Schwammberger</i>	1018
4.2.1.3. Caso <i>Priebke</i>	1019
4.2.2. Jurisprudencia extranjera.....	1020
4.2.2.1. Caso <i>Álvarez Machain</i>	1020
4.2.2.2. Caso <i>Pinochet</i>	1021
4.2.3. Jurisprudencia internacional.....	1022
4.2.3.1. Caso de la <i>Orden de arresto</i>	1022
4.2.3.2. Caso de la <i>Obligación de juzgar o extraditar</i>	1023

CAPÍTULO 1

EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Emiliano J. Buis

1. Introducción: el derecho internacional público y su importancia

"El derecho internacional no sirve", "el derecho internacional es pura política y es muy poco jurídico", "el derecho internacional es un instrumento que solamente favorece a los países más poderosos" o "el derecho internacional es solamente una expresión de deseo, que recurre a conceptos abstractos —como seguridad, paz y fraternidad de las naciones— que son irrealizables en la práctica" son cuatro de las muchas afirmaciones que suelen escucharse en las primeras clases de una asignatura que para muchos es apasionante, y para otros, un obstáculo que es preciso remontar en la búsqueda de un título habilitante.

Lo cierto es que, para los estudiantes acostumbrados a estudiar, en el diseño curricular de una facultad de Abogacía, el derecho "interno" del Estado nacional (como surge de los planes más tradicionales), el derecho internacional público¹ puede parecer una construcción lejana e, incluso, primitiva, en la medida en que una serie de características propias del ordenamiento doméstico (tales como la subordinación a un uso monopolístico de la fuerza, o la fuerza coercitiva para imponer medidas) no encuentran correlato en la lógica de este sistema. Ello hace que, en el mejor de los casos, se considere que al derecho internacional le faltan institutos o carece de ciertos elementos percibidos como fundamentales, de manera que corre una suerte desdichada en relación (y en comparación) con el "verdadero" derecho, que es —desde esta perspectiva— el que se crea desde el Estado para sus habitantes en el interior de sus fronteras. En el peor de los casos, estas falencias llevan a pensar que el derecho internacional ni siquiera puede ser considerado un orden de tipo jurídico.

Pensamientos de este tenor, sin embargo, requieren ser refutados y cualquier individuo interesado en el área jurídica debe darse cuenta de que no es posible comprender cabalmente el fenómeno del derecho sin dedicar tiempo a reflexionar sobre la lógica inherente del derecho internacional público. Es más, ya no es posible incluso concebir la posibilidad de un ejercicio de la profesión de abogado sin conocimientos consistentes de normas y principios sustanciales del derecho internacional, tal como ocurre con el derecho de los tratados o los mecanismos universales y regionales de protección de los derechos humanos.

Del conflicto en Siria a la controversia con Uruguay por la fábrica de celulosa en Fray Bentos, de la inclusión de Venezuela al MERCOSUR a la liberación de la fragata Libertad

¹ Utilizaremos en este capítulo las expresiones "derecho internacional público" y "derecho internacional" a secas como sinónimos; más adelante explicaremos de qué modo este ordenamiento se diferencia del llamado "derecho internacional privado" que, como parte de los sistemas jurídicos nacionales, goza de una naturaleza diferente y, por tanto, será siempre identificado como tal a través de la doble adjetivación.

por parte de las autoridades de Ghana o a la imputación en Rusia del delito de piratería a los manifestantes de Greenpeace –para citar ejemplos cercanos o recientes– hace falta saber derecho internacional para leer las páginas de un diario (o mirar los titulares en la pantalla de la computadora, si la lectura en celulosa deviene anacrónica), y mucho más para dedicarse a la administración de justicia, al servicio público en el Estado, a los litigios privados o al asesoramiento jurídico de empresas o particulares. En efecto, las fuentes del derecho internacional público integran nuestro ordenamiento jurídico y, como veremos, incluso lo hacen con jerarquía suprallegal y, en algunos supuestos, hasta constitucional.

Frente a las opiniones más críticas del derecho internacional, en estas páginas se intentará demostrar que: (1) el derecho internacional público es derecho, del mismo modo en que lo es el derecho interno, pero por sus particularidades no es a veces posible comprenderlo o examinarlo desde criterios de análisis externos como los que sirven tradicionalmente para entender los ordenamientos estatales; (2) el derecho internacional público es (y siempre ha sido) resultante de la voluntad de los Estados, cada uno de los cuales constituye una entidad soberana que no reconoce ninguna autoridad superior a él que pueda imponerle conductas o comportamientos; (3) el derecho internacional público es un ordenamiento jurídico que, desde su formulación clásica en la Edad Moderna, se sustenta mayormente en la coordinación (o "parataxis") y en una estructura descentralizada, que, sin embargo, no deja de lado institutos de subordinación ("hipotaxis") que proceden de sus orígenes más remotos en épocas preclásicas; (4) al igual que el derecho interno (y he aquí quizás su principal semejanza), el derecho internacional público es un ordenamiento positivo en el que coexisten dos aspectos centrales cuya confluencia hace de él un producto único: la pretensión de justicia (y la consecuente pretensión pacifista de lograr una comunidad fraterna de naciones) y la legitimación discursiva de las acciones realizadas (o que pretenden ser hechas) por parte de los Estados. Esta característica, que es inherente pues al derecho internacional, habilita a pensar una continuidad diacrónica y una coherencia desde sus primeras manifestaciones hasta nuestros días: quizás en mayor medida que los ordenamientos nacionales, el avance del derecho internacional está impregnado de intereses políticos y consideraciones extrajurídicas, y en esto precisamente se encuentra la riqueza de su estudio.

Para avanzar con estas cuestiones, corresponde primero explicitar qué entendemos por derecho internacional público. Ello nos llevará, en un comienzo, a discutir la naturaleza misma del derecho y sus fundamentos históricos, políticos y sociales.

2. El derecho y el Estado

Suele decirse que el derecho es una construcción social, un producto creado para la solución de divergencias en el seno de una comunidad. Si ese es su fin primordial, no hay duda de que su propia existencia depende, por tanto, de la existencia del conflicto. Entendido así, desde sus propios orígenes el derecho como institución ha servido como mecanismo regulatorio y civilizador, para evitar la venganza como medio de arreglo de disputas y para establecer (e imponer) criterios de convivencia en el seno de una organización humana. Es evidente, entonces, que el derecho se origina como corolario del hecho de que los hombres, lejos de vivir en soledad, empiezan a interactuar y pronto descubren sus discrepancias. En un principio, se dejaba el arreglo librado a la pura fuerza y, por lo tanto, el más fuerte se imponía sin condiciones frente a su adversario débil. Con el paso del tiempo, se ha dado lugar a la búsqueda de alternativas menos violentas: en efecto, desde los primeros asentamientos, los seres humanos se han dotado de reglas destinadas a propugnar el restablecimiento del orden en caso de ruptura. Este derecho, entonces, depende en su formación y alcances del surgimiento de grupos políticos en un territorio determinado y con ciertos órganos de ejercicio de la autoridad. Desde sus propios orígenes, la idea de derecho parece inescindible, pues, de la idea de Estado (si, por supuesto, entendemos que hay Estado en la medida en que se trate de una organización política que posea una población particular, un territorio y un gobierno).

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la doctrina clásica suele concebir el derecho desde una definición formal, que presta atención en particular a su contenido, al modo en

que ese contenido se determina y a aquellos sujetos involucrados. "Derecho" sería, entonces, el sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones que se dan entre quienes componen ese grupo humano, a los que el propio ordenamiento considerará sus sujetos (es decir, los centros de imputación de las normas, quienes podrán adquirir derechos o contraer obligaciones en el seno de dicho sistema).

Sabemos que una norma, del carácter que sea, es un patrón de conducta o un paradigma de comportamiento esperable. A diferencia de las normas establecidas en el plano moral, ético, social o religioso, una norma jurídica no impone de manera directa un modelo de acción, sino que presenta una estructura compleja: la norma jurídica establece, de modo indirecto, que, frente al caso en que un sujeto incumpla determinado precepto, recibirá una sanción. Esto es lo que Hans Kelsen (1881-1973) identificó como las dos partes de las que se compone lógicamente la norma básica de todo ordenamiento de derecho: el antecedente y el consecuente (o sanción)². Pero, dado que el derecho es una ciencia particular, ese vínculo condicional no se va a dar, sin embargo, de manera necesaria, como ocurriría en el plano de las normas físicas, en que la relación "es" (p. ej., "si tiro un lápiz, entonces es que cae al suelo"); en el derecho el vínculo entre antecedente y consecuente integra la dimensión del "deber ser" (p. ej., "si A comete un homicidio, entonces debe ser que A reciba una pena de X años de prisión"). Con esta técnica de motivación indirecta, las normas jurídicas lograrán regular las relaciones entre los sujetos a partir de la creación, modificación o extinción de derechos y/o obligaciones.

A estas "reglas primeras" propias del modelo positivista simple propuesto por Kelsen, un autor como H. L. A. Hart (1907-1992) agregará la necesidad de incluir las normas de tipo secundario, que son aquellas que sirven para identificar qué reglas forman parte del sistema (reglas de reconocimiento), de modo de poder determinar los procedimientos necesarios para crear nuevas reglas primarias o modificar las existentes (reglas de cambio) o para dar competencia a los jueces a los efectos de que establezcan si se ha violado o no una regla primaria en una situación concreta (reglas de adjudicación)³. El derecho, cualquiera sea su particularidad, estaría integrado por estas normas jurídicas en su conjunto.

Pero esas normas no están aisladas ni integran el ordenamiento jurídico de modo azaroso. Todo lo contrario, el derecho supone una imbricación profunda de estas normas, que se presentan como interrelacionadas e interdependientes. Se trataría no de un mero conjunto (entendido como sumatoria de unidades, sin ninguna estructura interna), sino de un verdadero sistema (es decir, un conjunto ordenado, en el que cada uno de los elementos tiene un papel fundamental en su relación con el resto de los elementos). Cada derecho, por lo tanto, es un orden complejo en el que toda norma jurídica cobra sentido y valor pleno solamente en función de las otras⁴.

El concepto de sistema implica una voluntad ordenadora muy propia de la centralización progresiva que supone la idea de Estado. En efecto, cuando las comunidades humanas van superando el simple modelo familiar para consolidar sobre su misma base un modelo de jefatura que lo complementa –muy pronto en el tiempo, cuando surge la revolución urbana en época neolítica–, se va organizando el orden político y aparece el derecho como medio de solución de conflictos impuesto por quien ejerce el poder en el grupo. La comunidad políticamente organizada se sostiene en un principio verticalista que permite la imposición de la respuesta del derecho en caso de controversias. O, si se prefiere seguir la expresión del sociólogo Max Weber (1864-1920), desde sus comienzos

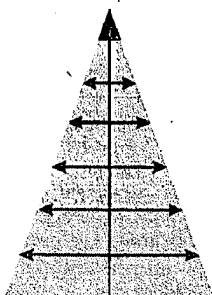
² Kelsen, Hans, *Teoría pura del derecho*, Eudeba, Buenos Aires, 1982. El texto original en alemán, *Reine Rechtslehre*, fue publicado por primera vez en 1934 y en una segunda edición –con cuantiosas modificaciones– en 1980.

³ Hart, Herbert L. A., *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1961.

⁴ Se nos permitirá aquí hacer una comparación interdisciplinaria con la lingüística, dado que este concepto de "sistema" al que nos referimos encuentra fundamento en la teoría estructuralista. El derecho como sistema de normas jurídicas es semejante a lo que Ferdinand de Saussure (1857-1913) define como "lengua", entendida como un sistema de signos lingüísticos (significado / significante) en el que cada uno tiene valor por oposición a los otros. Las ideas expuestas al respecto por de Saussure en sus clases fueron recopiladas póstumamente por sus discípulos Bally, Charles y Séchéhaye, Albert, en su *Cours de linguistique générale*, Payot, Lausanne y París, 1916.

el Estado se caracteriza por ejercer el monopolio legítimo de la violencia⁵. Ese uso de la fuerza se manifiesta en la posibilidad de imponer el derecho a los sujetos que integran el ordenamiento y, por lo demás, en la necesidad de asegurar el respeto: frente a las infracciones o incumplimientos, el *imperium* de que goza el Estado se traduce en la coerción. Todos los que integran el sistema jurídico deben respetar las decisiones estatales, bajo riesgo de ser compelidos a ello por los mecanismos de la fuerza pública que aseguran el cumplimiento (*enforcement*) de las normas jurídicas. En términos gráficos, pues, y en homenaje a los planteos de Kelsen, se nos permitirá ilustrar esta conceptualización del derecho propio de cada Estado con el diseño de una pirámide cuyo extremo superior supone la cúpula estatal y cuyas líneas inferiores dan cuenta de los estratos de control jurídico sobre cada uno de los sujetos.

El derecho doméstico



El gráfico es ilustrativo, pues, porque permite explicar que el derecho interno supone un ordenamiento jurídico centralizado y verticalista, en el que existe una subordinación de los sujetos a la propia entidad estatal (ello, por supuesto, con independencia de los fundamentos históricos o teóricos de la creación de este Estado como tal). Es lo que podemos llamar, entonces, una lógica "hipotáctica" del derecho, es decir, un sistema en el que hay una dependencia evidente por parte de los sujetos a una normativa a la que están sometidos o subordinados⁶. ¿Cómo pensar, entonces, en la lógica del derecho internacional público sobre esta base?

3. El derecho internacional, su concepto y evolución histórica: ¿de la subordinación a la coordinación?

3.1. Concepto de derecho internacional público. Relación con otras disciplinas

Frente al derecho nacional, que se desarrolló fronteras hacia adentro para ejercer un control centralizado sobre los individuos-sujetos, el derecho "internacional" (*international law*, llamado así por primera vez por J. Bentham a fines del siglo XVIII)⁷ nace con el propósito de

⁵ Esta expresión surge de su célebre conferencia "Politik als Beruf" ("La política como vocación"), presentada en la Universidad de Múnich en 1919.

⁶ He aquí nuestra segunda metáfora lingüística. Tomamos prestado el término "hipotaxis" de los estudios sintácticos. Allí se utiliza para mostrar de qué modo, en una oración, es posible establecer proposiciones en grado de subordinación a otras que resultan principales. Ello ocurre, por ejemplo, en la medida en que, de las oraciones simples "Yo digo" y "María estudia derecho", puedo derivar una oración compuesta en la que la segunda cláusula resulte dependiente de la primera: "Yo digo que María estudia derecho". La palabra *hipotaxis* viene de dos términos griegos: *hypó* ("debajo de") y *táxis* ("ordenamiento", del verbo *tásein*, "organizar", "poner en orden"): es colocar o disponer algo en una posición subalterna respecto de otra cosa.

⁷ Lafleur, Laurence (ed.), *Bentham, J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), Hafner Pub. & Co., Nueva York, 1963.

dar un marco normativo a los vínculos entre los propios Estados⁸. A pesar de sus diferencias de base con los derechos internos, puede afirmarse que el derecho internacional cumple con la misma función social que caracteriza al derecho en términos generales, en tanto se trata de un dispositivo que regula y controla el accionar de los sujetos que intervienen, condicionando sus comportamientos en un supuesto y pretendido beneficio de todos⁹.

En la actualidad, entonces, podemos definir al derecho internacional público como un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional¹⁰; por estos sujetos nos referimos históricamente, en esencia, a las entidades estatales o, para ser más precisos todavía, si pensamos en el derecho internacional moderno, a los Estados (como sujetos principales) y a otros actores a los que el propio ordenamiento otorga personalidad jurídica¹¹. A pesar de la existencia de estos nuevos actores que intervienen con roles muy marcados en la realidad internacional, suele decirse que el derecho internacional sigue siendo en la actualidad un sistema que predominantemente es creado por Estados¹². Es, en definitiva, el orden jurídico internacional¹³.

Reconocemos que esta aproximación, claramente positivista, no da cuenta de otros aspectos que parecen inherentes al concepto, sobre todo en lo que hace a sus fundamentos morales¹⁴. No nos interesa, sin embargo, discutir las múltiples definiciones que la doctrina ha elaborado a lo largo de los siglos para acotar el concepto¹⁵. Si conviene señalar aquí que, como analizaremos en apartados siguientes, en la noción de derecho internacional –en sus diferentes formulaciones– siempre se destaca la idea de un ordenamiento que los propios Estados han creado para regular sus conductas. Esto ha llevado a varios autores a plantear, a la luz de los sistemas internos, que el derecho internacional no comparte las características inherentes de lo que llamamos "derecho"¹⁶. Así, por ejemplo, el filósofo John Austin hablaba de una "moralidad positiva" al referirse al derecho internacional, dado que se trataba de un orden jurídico en el que las normas dictadas por un soberano no estaban respaldadas por una sanción o castigo¹⁷. Por su parte, también a la luz de los derechos internos, Kelsen sostenía que estábamos en presencia de un orden "primitivo" en el que todavía no se había alcanzado el grado de centralización

⁸ Acerca de la terminología correspondiente, ver Fisch, Jörg, "Peoples and Nations", en *The Oxford Handbook of the History of International Law*, Fassbender, Bardo y Peters, Anne (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 28-30.

⁹ Allott, Philip, "The Concept of International Law", *European Journal of International Law*, vol. 10, n.º 1 (1999), pp. 31-50.

¹⁰ Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Radl E. y Gutiérrez Posse, Hortensia, *Derecho Internacional Público*, Zavalla, Buenos Aires, t. I, 1997, p. 14; Ruzié, David, *Droit international public*, Dalloz, París, 19.ª edic., 2008, p. 1.

¹¹ A partir de fines del s. XIX, los propios Estados –en tanto sujetos principales del ordenamiento– atribuyeron derechos y obligaciones internacionales a organizaciones, individuos y otras entidades que, por ello, resultarían sujetos derivados con capacidad jurídica restringida. El problema de la subjetividad internacional será desarrollado de modo preciso en el capítulo 2.

¹² Malanowski, Peter, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Routledge, Nueva York y Londres, 1997, p. 2. En un comienzo, muchos autores describían el derecho internacional público como aquel que regía las conductas de los "Estados civilizados", como muestran las varias definiciones tradicionales reproducidas en Verma, S. K., *An Introduction to Public International Law*, Phi Learning Pvt. Ltd., Nueva Delhi, 2004, p. 1.

¹³ Díez de Velasco Vallejo, Manuel, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Tecnos, Madrid, 1978, p. 61.

¹⁴ En este sentido, corresponde mencionar a John Rawls (*The Law of Peoples*, Harvard University Press, Cambridge, 1999), quien propone un ordenamiento jurídico que regule las relaciones entre pueblos (y ya no Estados) que sean "razonablemente liberales" y "decentes" (pp. 23-25 y 64-67). Un estudio de este texto y su visión acerca del derecho internacional puede hallarse en Tasioulas, John, "From Utopia to Kazakhstan: John Rawls and the Law of Peoples", *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 22, n.º 2 (2002), pp. 367-396.

¹⁵ Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 7.ª edic., 2008 –quizás el principal manual de la disciplina– opta por no definir al derecho internacional, sino que directamente se ocupa de analizar sus diferentes modos de creación (fuentes). Acerca de una "desconfianza" genérica en las definiciones sobre el derecho internacional, cfr. Barboza, Julio, *Derecho Internacional Público*, Zavalla, Buenos Aires, 2008, pp. 11-12.

¹⁶ Inspirados generalmente en las ideas de Thomas Hobbes (1588-1679); sobre estas posturas y sus críticas, cfr. Mégret, Frédéric, "International law as law", en *The Cambridge Companion to International Law*, Crawford, James y Koskeniemi, Martti (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 72-81.

¹⁷ Hart, Herbert L. A. (ed.), *Austin, J. The Province of Jurisprudence Determined*, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1954.

requerido para imponer las normas jurídicas mediante coerción¹⁸. De modo semejante, Hersch Lauterpacht consideraba que el derecho internacional era un derecho primitivo (*primitive law*) porque carecía de una autoridad legislativa centralizada y de tribunales con jurisdicción compulsiva¹⁹.

Estos argumentos escépticos o "negacionistas" –hay que decirlo– parten de la suposición de que los derechos nacionales son el "modelo" jurídico que debe ser seguido, entendiendo, entonces, el derecho internacional como un ordenamiento al que le faltan propiedades necesarias para asimilarlo a los primeros²⁰. Creemos, en cambio, que el derecho internacional es derecho propiamente dicho (aunque distinto en su naturaleza de los sistemas domésticos) en la medida en que sus normas originan obligaciones y derechos aceptados por los sujetos para su convivencia²¹. La falta de mecanismos concretos de ejecución (*enforcement*), por cierto, en nada afectan la condición jurídica del derecho internacional, como ha sostenido de modo contundente uno de los jueces de la Corte Internacional de Justicia al referirse a la naturaleza vinculante de las medidas provisionales:

El hecho de que una decisión no pueda hacerse cumplir no afecta de ninguna manera su naturaleza obligatoria, puesto que la naturaleza obligatoria de una decisión es inherente a ella misma. Impone una obligación positiva reconocida por el derecho internacional. Si dicha decisión es o no cumplida, si puede o no imponerse el cumplimiento de dicha decisión, qué otras sanciones yacen detrás –todas estas son cuestiones externas, que no afectan la cuestión interna de la validez inherente–²².

No debe confundirse el derecho internacional con la moralidad internacional o reglas de cortesía (*comity*) que los Estados han respetado tradicionalmente en sus relaciones mutuas (tales como la recepción formal de los mandatarios extranjeros o el saludo de buques en altamar), dado que estas no generan conciencia alguna de obligatoriedad en quien las realiza, mientras que aquel corresponde a un plano verdaderamente jurídico: en el derecho internacional, es evidente la presencia de pautas de conducta cuyo cumplimiento es percibido como una obligación de derecho y cuya violación acarrea consecuencias jurídicas.

Tampoco debe confundirse con la política internacional o con la economía internacional. Por supuesto, el carácter político-económico del derecho internacional público es evidente desde sus primeros pasos, pero es preciso diferenciar su naturaleza conceptual (el hecho de constituir un sistema de normas de derecho) del análisis de las propias relaciones que el derecho se encarga de regular: estas relaciones interestatales, los vínculos que los Estados generan entre sí motivados por un sinnúmero de razones, son el objeto de estudio de otras disciplinas, como pueden ser las relaciones internacionales, la ciencia política o la economía internacional. Pero tratándose de ámbitos de estudio radicalmente diferentes, no corresponde postular una escisión pragmática, atento a que no es posible comprender enteramente los vaivenes de las relaciones entre Estados desde una clave exclusivamente basada en el derecho, ni resulta concebible comprender la compleja realidad internacional desde una lectura política o económica

que ignore la variable jurídica²³. Solamente una perspectiva interdisciplinaria (o, al menos, interesada en las diversas ópticas de estudio) podrá potenciar la riqueza de cada campo en una visión comprensiva del fenómeno, y desde ese lugar el estudio del derecho internacional puede ofrecer aportaciones esenciales.

De manera semejante a otras disciplinas y campos sociales vinculados con la ética, la religión, la economía o la política, el derecho internacional tiende a regular conductas, pero –como veremos– se trata radicalmente de una esfera distinta, con sus reglas específicas (de carácter jurídico) y con particularidades propias.

3.2. El derecho internacional preclásico (hasta 1648): subordinación, falta de teorización, particularismo

Definido el derecho internacional y sus límites con otras disciplinas, cabría preguntarse, entonces, cuál fue su origen, cómo se generan sus reglas y cuáles son sus características. Empecemos diciendo que el derecho internacional es un producto social y que, desde ese lugar, constituye una construcción histórica²⁴.

Desde una visión diacrónica, es evidente que el nacimiento del derecho internacional no es reciente²⁵; de hecho, sus primeras manifestaciones pueden remontarse al mundo antiguo²⁶. Así, una visión realista de las relaciones internacionales identifica la existencia de una práctica inmemorial entre los Estados que se han vinculado siempre en múltiples niveles, teniendo en cuenta sus diferencias respecto a poder político, capacidad económica y aptitudes para negociar. El sistema jurídico internacional, desde esta perspectiva, sería el resultado de una serie de interrelaciones entre entidades que resultan notoriamente diferentes y que interactúan desde un plano de considerable desigualdad, lo que hace en definitiva que los Estados con mayor cintura para imponer su cosmovisión sean los que consiguen moldear las normas jurídicas (e imponerlas a los Estados más débiles o pobres) en función de su conveniencia e intereses²⁷. Gráficamente, podríamos representar esta imagen realista del derecho internacional desde un esquema también hipotético que –a diferencia de lo que ocurría en los ordenamientos internos– coloca en la cima a los Estados más poderosos y como subordinados al resto de los Estados que integran la comunidad internacional.

18 Kelsen, Hans, *Principles of International Law*, Rinehart & Co., Nueva York, 1952, p. 32.

19 Lauterpacht, Hersch, *The Function of Law in the International Community*, Oxford University Press, Oxford, 1933, p. 405.

20 Cassese, Antonio, "Origins and Foundations of the International Community", en *International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 3-46, se ha encargado bien de estudiar el derecho internacional en sus diferencias sustanciales con el derecho interno, sosteniendo que se trata de un derecho que no tiene en mira al individuo y cuyas particularidades se explican por el carácter único del orden mundial.

21 Se puede hablar de un cumplimiento voluntario (*voluntary compliance*) que hace que sea un verdadero derecho, como indica Henderson, Conway W., *Understanding International Law*, Wiley-Blackwell, Chichester & Malden, 2009, p. 5.

22 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia-Herzegovina c. Yugoslavia –Serbia y Montenegro–), ICJ, Providencia, 13/09/1993, Opinión Separada del magistrado Christopher G. Weeramantry, *ICJ Reports 1993*, p. 374 (traducción propia).

23 Higgins, Rosalyn, "The Nature and Function of International Law", en *Problems and Process: International Law and How We Use It*, Oxford University Press, Oxford, 1985, pp. 2-4, ha señalado que el derecho internacional –en tanto construcción social que no puede independizarse del hecho político– no puede ser reducido a las meras "reglas", sino a un proceso que está íntimamente relacionado con el ejercicio de la autoridad.

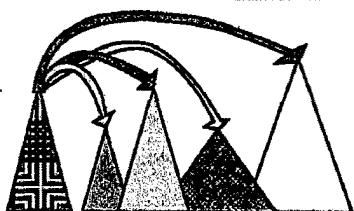
24 Acerca de la historia del derecho internacional y su importancia teórica, ver Redolob, Robert, *Histoire des grands principes du droit des gens depuis l'antiquité jusqu'à la veille de la grande guerre*, Rousseau, Paris, 1923; Versluis, Jan H.W., *International Law in Historical Perspective*, Martinus Nijhoff, Leiden, vol. 1, 1966; Hueck, Ingo, "The Discipline of the History of International Law", *Journal of the History of International Law*, vol. 3 (2001), pp. 194-217; Gaurier, Dominique, *Histoire du droit international. Auteurs, doctrines et développement de l'Antiquité à l'aube de la période contemporaine*, PUR, Rennes, 2005 y, fundamentalmente, Koskenniemi, Martti, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

25 Anand, R. P., "The Influence of History on the Literature of International Law", en *The Structure and Process of International Law*, MacDonald, Ronald S. J. y Johnston, Douglas M. (eds.), Martinus Nijhoff, Dordrecht, Boston y Lancaster, 1983, p. 342.

26 Truyol y Serra, Antonio, *Historia del derecho internacional público*, Tecnos, Madrid, 1998, p. 15. Del mismo modo se expresa Arribas, Juan José M., *Derecho internacional: Bases y tendencias actuales*, Entimema, Madrid, 2007, pp. 41-45.

27 Krish, Nico, "International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order", *European Journal of International Law*, vol. 18 (2005), pp. 399-408.

El DIP y la práctica interestatal
(modelo realista hipotético)



Esta lectura es, sin embargo, propia de una mirada política del fenómeno, que subordina el derecho a la decisión de los Estados que ejercen mayor poder relativo sobre el resto. El fundamento de esta teoría, por cierto, es histórico, dado que se sostiene que, desde los orígenes mismos de las primeras comunidades políticamente organizadas, los Estados más influyentes procuraron imponerse, mediante una serie de normas jurídicas que los beneficiaban, a los menos favorecidos.

Esto es lo que caracteriza mayormente al derecho internacional preclásico²⁸. La Antigüedad nos brinda una serie de interesantes ejemplos para pensar de qué manera el derecho internacional sirvió como instrumento de dominación de los poderosos²⁹. En estas primeras manifestaciones hallamos un derecho escasamente sistematizado, carente de un fundamento teórico-científico (no existía una doctrina que lo describiera y explicara) y con un carácter esencialmente particular: se trataba de normas que carecían de validez universal pero que, en los vínculos entre comunidades vecinas, generaban derechos y obligaciones (en general a través de tratados bilaterales) para las partes involucradas, de acuerdo con las capacidades que cada una de ellas tenía para persuadir, defender sus intereses y proyectar sus puntos de vista.

Pensemos, por ejemplo, en las interacciones que tuvieron lugar entre las comunidades del Cercano Oriente antiguo desde el tercer milenio antes de la era cristiana, donde se advertía con suma claridad la dominación de unas sobre otras y la sucesión y alternancia de ciudades-Estado victoriosas³⁰. Este modelo de expansión territorial y subordinación jurídica es claro en el enfrentamiento de los grandes imperios de la región hacia el primer milenio, como lo atestigua la batalla de Kadesh, librada entre los egipcios y los hititas hacia el 1280 a. C., que dio lugar al texto del primer tratado de paz preservado hasta nuestros tiempos.

En el caso de las ciudades griegas clásicas, también se advierte cómo se construye un derecho internacional a partir de la imposición de ciertos acuerdos por parte de las *poleis* más poderosas: es el caso –por ejemplo– de Esparta, que, en varias ocasiones durante el siglo V a. C., firmó tratados en los cuales impuso a sus aliados el deber de poseer los mismos amigos y enemigos que tenían los espartanos³¹.

28 Acerca del derecho internacional en la Antigüedad, cfr. Phillipson, Coleman, *The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, Macmillan, Londres, vol. II, 1911; Ruiz Moreno, Isidoro, *El derecho internacional antes de la Era Cristiana*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires, 1946; Bederman, David J., *International Law in Antiquity*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

29 Para una explicación detallada de la función de los tratados en el mundo antiguo, cfr. Buis, Emiliano J., "Sobre gnómos y gigantes: los tratados grecorromanos y la igualdad soberana de los Estados como ficción histórico-jurídica", *Lecciones y Ensayos*, vol. 89 (2011), pp. 73-117.

30 Liverani, Mario, *Relaciones Internacionales en el Próximo Oriente Antiguo, 1600-1100 a. C.*, Bellaterra, Barcelona, 2003, pp. 71-79.

31 Sobre la hegemonía en las relaciones interestatales del mundo helénico, cfr. Alonso Troncoso, Víctor, "Algunas consideraciones sobre la naturaleza y evolución de la *symmakhía* en época clásica (I)", *Anexo de Gerión*, vol. II (1989), pp. 165-179; "La cláusula de la hegemonía en la Liga Délica (Th. 3.10.4; 11.3)", *Ktéma*, vol. 27 (2002), pp. 57-63; "L'institution de l'hégémonie: entre la coutume et le droit écrit", en *Symposium 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Pazo de Marifán, La Coruña, 6-9. September 1999) (Akten der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte, 14), Thür, G. y Fernández Nieto, F.J. (eds.), 2003, pp. 339-354.

Pero quizás el ejemplo más interesante para nuestra lectura es el caso de Roma, que, especialmente en el pasaje de la República al Imperio (fines del siglo I a. C.), consolidó una política expansionista por el Mediterráneo que, basada en un derecho internacional ("derecho de gentes" o, en latín, *ius gentium*), la llevó a suscribir numerosos tratados, primero con otros pueblos itálicos, luego con ciudades y regiones del Oriente y del Occidente, consolidando progresivamente su supremacía (*maiestas*) e imponiendo su *imperium* a todo el mundo conocido que la rodeaba³².

En el ámbito romano, por cierto, hallamos quizás los primeros intentos por concebir la naturaleza del derecho internacional³³. Así, el incipiente desarrollo teórico respecto del fundamento del derecho de gentes (*ius gentium*) permite concebir a este como el conjunto de normas aplicables a las relaciones de Roma con las otras comunidades estatales y, al mismo tiempo, como el derecho aplicable a los vínculos que se daban entre ciudadanos romanos y personas extranjeras. En este doble sentido, el derecho de gentes era determinado en sus alcances por los propios magistrados romanos y complementaba, como sostiene el jurista Gayo en un manual de derecho del siglo II d. C., el derecho interno romano:

Todos los pueblos que están regidos por la ley y por la costumbre aplican en parte un derecho que les es propio y en parte un derecho común a todos los hombres. Pues el derecho que cada pueblo constituyó para sí mismo le es propio y se llama derecho civil (*ius civile*), casi como designando el derecho propio de la ciudad (*civitatis*). Pero lo que la razón natural estableció entre los hombres se observa igualmente entre todos los pueblos y se llama derecho de gentes (*ius gentium*), como designando el derecho que aplican todos los pueblos (*omnes gentes*). También el pueblo romano aplica en parte su propio derecho y en parte el derecho común a todos los hombres (*Institutas*, 1.1.)³⁴.

¿En qué consiste, pues, este derecho de gentes romano que resulta común a todos los pueblos? El jurista Hermogeniano, citado en el *Digesto* (1.1.5) enuncia una serie de aspectos que eran cubiertos por la noción y constituían el objeto de su regulación:

A este derecho de gentes (*ius gentium*) corresponden la declaración de guerra, la separación entre pueblos diferentes, la fundación de reinos, la división de las propiedades, el hecho de poner límites a las tierras, la disposición de los edificios, el comercio, las compras, las ventas, ofertas y demandas de arriendo, las reglas que regulan las obligaciones, con excepción de las que hayan sido introducidas por el derecho civil (*a iure civili*)³⁵.

El pasaje permite concluir que el *ius gentium* romano abarcaba tanto las normas que hoy consideraríamos parte del derecho internacional público (esto es, las que regulaban las relaciones interestatales en las que Roma estaba involucrada) como lo que conocemos actualmente como derecho internacional privado (es decir, las normas que regulan las cuestiones jurídicas en las que están involucrados los sujetos de derecho interno –en ese caso, los ciudadanos roma-

32 Cfr. Kallet-Marx, Robert M., *Hegemony to Empire: The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*, University of California Press, Berkeley, 1995; Ferrary, Jean-Louis, "Traité et domination romaine dans le monde hellénistique", en *I trattati nel mondo antico. Forma, ideologia, funzione*, Canfora, Luciano; Liverani, Mario y Zaccagnini, Carlo (eds.), «L'Erma» di Bretschneider, Roma, 1990, pp. 217-235.

33 Al respecto, ver Buis, Emiliano J., "Las lágrimas de Zeus, la prudencia de Atenea: Normas humanitarias, fuentes históricas y el reconocimiento de un 'derecho internacional' en el mundo griego antiguo", *Revista Jurídica de Buenos Aires*, 2012, pp. 357-383, donde también sugerimos un razonamiento semejante para el caso de las ciudades-Estado de la Grecia clásica.

34 *Gai Institutiones or Institutes of Roman Law*, traducción y comentarios de Poste, Edward, con una introducción histórica de Greenidge, A.H.J., Clarendon Press, Oxford, 4.ª ed. rev. por Whittuck, E.A., 1904 (traducción propia).

35 Mommsen, Theodor y Krueger, Paul (eds.), *Digest of Justinian*, traducido por Watson, Alan, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1985 (traducción propia).

nos-, pero en las que existe algún elemento extranjero o vinculado con otras naciones³⁶. Hoy en día ambas disciplinas suponen ámbitos independientes desde el punto de vista didáctico y conceptual³⁷, como ha señalado la Corte Permanente de Justicia Internacional en su decisión acerca de la emisión de préstamos serbios:

Todo contrato que no sea un acuerdo entre Estados en su capacidad de sujetos del derecho internacional se basa en el derecho interno de un país. La pregunta respecto de lo que es este derecho forma parte de aquella rama jurídica que, en la actualidad, suele describirse como derecho internacional privado o la "doctrina del conflicto de leyes". Las reglas respectivas pueden ser comunes a varios Estados y pueden incluso haber sido establecidas por convenciones o costumbres internacionales, y en este último caso pueden poseer el carácter de un verdadero derecho internacional que gobierna las relaciones entre Estados. Pero, más allá de esto, debe considerarse que estas reglas forman parte del derecho interno³⁸.

El pasaje jurisprudencial constituye una muestra expresa de la diferenciación concreta que existe hoy entre los dominios jurídicos del derecho internacional público y el derecho internacional privado. La reflexión que subyace allí es, no obstante, moderna. Antes de 1848, como hemos dicho, existía una superposición de ambos cuerpos normativos. Analizar entonces el *ius gentium* romano, y describirlo a la luz de su lógica hipotáctica, resulta interesante para comprender hasta qué punto lo que llamamos derecho internacional público era originado, durante el mundo preclásico –del mismo modo que lo es hoy el derecho internacional privado–, en el seno de cada Estado (y fundamentalmente de los Estados más poderosos para imponerse a otros).

El sustento teórico natural de un *ius gentium* fundado en normas comunes a todos los hombres³⁹ fue percibido como incompatible con la manipulación política de estas reglas en beneficio práctico de Roma⁴⁰. Esta distancia es teorizada durante la Edad Media, en la que se intentó compatibilizar la naturaleza inmutable de los principios que dan origen al derecho de gentes (considerados divinos) con aspectos prácticos del ejercicio de la autoridad secular. Esto se advierte con claridad en la principal obra medieval al respecto, la *Summa Theologiae* de Santo Tomás de Aquino (1225-1274)⁴¹.

36 Acerca de esta definición de derecho internacional privado, cfr. Battifol, Henri, *Droit international privé*, Librairie générale, París, 1970, p. 2; Aust, Anthony, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 1-3; Biocca, Stella Maria; Feldstein de Cárdenas, Sara L. y Bass, Victoria, *Lecciones de Derecho Internacional Privado, Parte General*, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1990, pp. 19-21 (se incluyen aquí otras definiciones del concepto). Pueden consultarse, además, Alcoria, Amancio, *Curso de derecho internacional privado*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires, 1927; Boggiano, Antonio, *Derecho Internacional Privado*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. 1, 2008; Vico, Carlos M., *Curso de Derecho Internacional Privado*, Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1956.

37 De hecho, el derecho internacional privado –al menos en su concepción tradicional– forma parte del ordenamiento interno de los Estados: se trata de determinar, ante una situación en la que existen elementos que forman parte de dos o más países, cuál es el derecho aplicable y cuál es la jurisdicción competente para decidir. Así, por ejemplo, es el derecho internacional privado el que se ocupa de resolver controversias referidas a un divorcio que tiene lugar en un determinado Estado entre ciudadanos de otros Estados que contrajeron matrimonio en el exterior, o a la quiebra de una empresa transnacional con capitales en distintos países. En esa circunstancia, se trata de determinar cuál de los ordenamientos domésticos es el que el juez deberá aplicar (por ser el más adecuado a la relación) para resolver el caso. Resulta claro, entonces, que el derecho internacional privado, en cuanto a su naturaleza, integra el derecho nacional y, por lo tanto, responde a la lógica hipotáctica que hemos descrito en el apartado anterior.

38 *Empréstitos serbios emitidos en Francia*, (Francia c. Reino de los Serbios, Croacia y Eslovenia), CJI, Fallo, 12/7/1929, CJI Serie A, n.º 20, p. 41 (traducción propia).

39 Este iusnaturalismo puede ser leído como un idealismo legal (*legal idealism*) (van Hoof, G. *Rethinking the Sources of International Law*, Kluwer, Deventer y Londres, 1989, pp. 30-44).

40 Kaser, Max, *Jus Gentium*, Böhlau, Köln, Weimar y Wien, 1988. Al respecto, ver también Lombardi, Gabrio, *Sul concetto di "ius gentium"*, Istituto di Diritto Romano, Roma, 1947.

41 Por lo demás, sobre el derecho internacional en tiempos medievales a partir del ejemplo del imperio carolingio, puede leerse el trabajo de Stelger, Heinrich, *Die Ordnung der Welt. Eine Völkerrechtsgeschichte des karolingischen Zeitalters (741 bis 840)*, Böhlau, Köln, 2009. Cfr. también Hintzinger, Martin, "From the Late Middle Ages to the Peace of Westphalia", en *The Oxford Handbook of the History of International Law*, op. cit., pp. 607-627.

3.3. El derecho internacional clásico (1648-1945): coordinación, cientificidad, universalidad

A pesar de que, como hemos visto, las normas jurídicas del derecho internacional pueden encontrar orígenes concretos en el mundo antiguo, es habitual leer en la doctrina que el nacimiento del derecho internacional tal como lo concebimos tuvo lugar –luego de una Edad Media sumida en un régimen feudal de vasallaje en el que el poder estaba disperso, no existía la institución del Estado y la autoridad del *ius gentium* era mayormente teocrática– con el surgimiento de los Estados modernos, el descubrimiento de América por parte de las potencias europeas y la instalación de un racionalismo jurídico⁴². Si bien parece unánime en la doctrina el reconocimiento del carácter eurocéntrico del derecho internacional moderno⁴³, no todos los autores coinciden en plantear las causales y circunstancias de su desarrollo inicial.

Así, quienes sostienen que la llegada de los españoles a América generó el clima adecuado para el surgimiento del derecho internacional no se apartan en demasía de la concepción de un ordenamiento interestatal fundado en las pretensiones expansionistas de los grandes imperios, propias de la subordinación que hemos relevado en el mundo antiguo. La conquista de tierras "virgenas" en las Indias –que originó considerables reflexiones teóricas por parte de teólogos escolásticos españoles, tales como el dominico Francisco de Vitoria (1486-1546) o el jesuita Francisco Suárez (1548-1617)– motivó la consolidación de reflexiones en torno de la existencia de un derecho de gentes inmerso en un universo racional, establecido por Dios y, por lo tanto, fundado en el derecho natural. Frente a ello, el protestante Alberico Gentili (1552-1602) se basó en los testimonios antiguos para concebir un derecho que fuese capaz de regular el balance de poderes mediante el ejercicio político de las instituciones diplomáticas. Estas teorías contrapuestas de fines del siglo xv y comienzos del xvi sentaron el fundamento material concreto para discutir desde aspectos teóricos y prácticos cuestiones como la ocupación territorial y las guerras justas. En su renacer moderno, entonces, las discusiones teóricas sobre el derecho internacional giran en torno de la matriz del imperialismo⁴⁴, sus justificaciones y las necesidades de su limitación.

El derecho internacional encontrará un espacio para desarrollarse en el reconocimiento mutuo de la soberanía como característica esencial del Estado en la modernidad⁴⁵. Estas interpretaciones, que colocan a la soberanía en el centro de las discusiones, concluyen que el derecho internacional tiene su origen durante los siglos xvi y xvii al definirse un nuevo orden político, jurídico y religioso en Europa, cuando se consolidan las grandes potencias como España, Portugal, Francia, los Países Bajos o Suecia.

La llamada Paz de Westfalia, de 1648, que pone fin a la Guerra de Treinta Años entre católicos y protestantes, es concebida por estos autores como un punto de inflexión, en la medida en que en los tratados que la componen (los llamados acuerdos de Münster y Osnabrück) se deja entrever un mecanismo regulatorio basado en el equilibrio de poder⁴⁶. En este primer intento por "contractualizar" las relaciones interestatales en Europa⁴⁷ se definen las parti-

42 Simpson, Gerry, "International law in diplomatic history", en *The Cambridge Companion to International Law*, op. cit., p. 81.

43 Puede leerse una crítica al eurocentrismo en Onuma, Yasuaki, *A Transcivilizational Perspective on International Law*, Martinus Nijhoff, Leiden y Boston, 2010. De modo semejante, Freiser, Wolfgang, *Frühe völkerrechtliche Ordnungen der außereuropäischen Welt. Ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts*, Steiner, Wiesbaden, 1976, había establecido las bases para comprender el fundamento histórico de las normas internacionales fuera del contexto europeo (sus ideas han sido retomadas y actualizadas más recientemente por Kolb, Robert, *Esquisse d'un droit international public des anciennes cultures extra européennes*, Pedone, París, 2010). Del mismo modo, consultar Becker Leroy, Arnulf, "Eurocentrism in the History of International Law", en *The Oxford Handbook of the History of International Law*, op. cit., pp. 1034-1057.

44 Anghel, Anthony, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

45 Croxon, Derek, "The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty", *International History Review*, vol. 21 (1999), pp. 559-582.

46 Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl E. y Gutiérrez Posas, Hortensia, op. cit., p. 81.

47 Cfr. Bull, Hedley, *Anarchical Society. A Study of Order in World Politics*, Macmillan, Nueva York, 1977.

cularidades de un nuevo sistema de derecho europeo determinado por el reconocimiento de una comunidad internacional caracterizada por el principio de la igualdad soberana de los Estados. Estos, según traduce este nuevo principio, se reconocen recíprocamente como iguales en términos jurídicos: cada uno de ellos es soberano sobre su propio territorio y, por lo tanto, no puede verse afectado por el resto de los Estados, que también ejercen su autoridad, respectivamente, respecto de su propio espacio de incumbencia⁴⁸. El espíritu que deja Westfalia es que la limitación de los propios deseos de poder y de expansión asegura, de alguna manera, que los otros Estados respeten la integridad del espacio soberano ajeno. Queda asentada una lógica que repetirán los tratados de paz al menos hasta fines del siglo XIX⁴⁹. Se trata de un esquema que procura la pacífica coexistencia de Estados con intereses distintos, y no todavía de objetivos comunes⁵⁰.

Se suele fijar el origen específico del derecho internacional público en este momento porque se estima que la igualdad jurídica de los Estados establece un control de los intentos hegemónicos de los más poderosos para brindar un entramado normativo que solamente puede surgir del acuerdo entre entidades que se hallan en un perfecto balance⁵¹. La consagración de la Paz de Westfalia como instancia de nacimiento del derecho internacional público moderno implica pensar al "nuevo" ordenamiento jurídico como un sistema descentralizado⁵², horizontal⁵³, donde los Estados son los sujetos que crean las normas mediante el libre acuerdo de voluntades y en el que no hay instancia superior que pueda ejercer el control⁵⁴. Las diferencias reales entre Estados quedan disimuladas bajo un velo de equiparación que –sobre la base de la soberanía– constituye una ficción efectiva que seguirá signando el derecho internacional hasta nuestros días⁵⁵. El modelo westfaliano, en síntesis, responde a una lógica de coordinación que llamaremos *parataxis*, dado que representa un régimen autorregulatorio en el que los Estados mismos participan de la formulación de las reglas y resultan sus propios sujetos⁵⁶.

48 Repgen, Konrad (ed.), *Acta Pacis Westphalicae* (Hrsg. von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte), Serie III (Abteilung B: Verhandlungsakten. Band 1: Die Friedensverträge mit Frankreich und Schweden. 1: Urkunden. Bearb. von Antje Oeschmann), Münster, 1998 (disponible en: www.pax-westphalia.de).

49 Duchhardt, Heinz, "From the Peace of Westphalia to the Congress of Vienna", en *The Oxford Handbook of the History of International Law*, op. cit., p. 630.

50 Oakeshott, Michael, *On Human Conduct*, Oxford University Press, Oxford, 1991.

51 En rigor de verdad, es factible afirmar que la Paz de Westfalia constituye un mito fundador; al respecto, ver Beaulac, Stéphane, *The Power of Language in the Making of International Law. The Word Sovereignty in Bodin and Vattel and the Myth of Westphalia*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2004. De ningún modo significa esto que luego de mediados del siglo XVII ya no habrá lugar para la imposición hegemónica de normas jurídicas por parte de los Estados más poderosos, ni tampoco que antes de esa época no había pretensiones de ocultar las desigualdades bajo un velo discursivo de equiparación a través de tratados sinalagmáticos. Sobre el particular, cfr. Buis, Emiliano J., "Sobre gnomos y gigantes: los tratados grecorromanos y la igualdad soberana de los Estados como ficción histórico-jurídica", art. cit., pp. 73-117.

52 Barboza, Julio, op. cit., pp. 16-18; Sánchez, Víctor M., "¿Qué es el derecho internacional?", en *Derecho internacional público*, Sánchez, Víctor M. (dir.), Huygens, Barcelona, pp. 19-21.

53 Cfr. Cheng, Bin, "Introduction to the Subjects of International Law", en *International Law: Achievements and Prospects*, Badjaoui, Mohammed (ed.), Martinus Nijhoff, Dordrecht y La Haya, 1991, p. 88.

54 Combacau, Jean y Sur, Serge, *Droit international public*, Montchrestien, Paris, 8.ª edic., 1997, pp. 2-3, identifican un derecho interestatal (que responde a esta descentralización) que ocuparía un lugar intermedio entre lo que denominan el derecho estatal (en el nivel interno) y el derecho supranacional (en el que un tercero se encuentra por encima de los Estados).

55 Algunos estudios se han encargado de mostrar los límites de esta construcción teórica: ver, por ejemplo, Simpson, Gerry, *Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International Legal Order*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

56 *Parataxis* es, en la terminología lingüística, la técnica que consiste en colocar lado a lado los elementos que integran una unidad oracional. Conformada a partir del prefijo *para-* ("al lado de") y del mismo verbo *táxis* que ya hemos descrito, se trata de una expresión que resulta útil para referirse a la coordinación entre estructuras que, colocadas en el mismo plano de equilibrio, se encuentran yuxtapuestas.

El DIP moderno (modelo de paradigma westfaliano)



En definitiva, tras la Paz de Westfalia ya no es posible pensar el derecho internacional con la misma estructura tradicional hipotáctica vigente en los ordenamientos internos, en la medida en que se trata de un orden *inter pares* que, disimulando toda divergencia entre las entidades estatales, se aparta de la verticalidad y centralización del derecho doméstico. Las regulaciones acordadas para las relaciones entre Estados son determinadas por estos mismos, que las crean, modifican o extinguen, y que a su vez deben velar por su cumplimiento. Quizás una de las manifestaciones más claras de la influencia del modelo westfaliano en la conceptualización actual del derecho internacional es el caso *Lotus*, en el que la Corte Permanente de Justicia Internacional reconoció que:

El derecho internacional regula las relaciones entre Estados independientes. Las reglas de derecho que vinculan a los Estados provienen pues de la voluntad de estos, voluntad manifestada en convenciones o prácticas que generalmente son aceptadas como consagración de principios de derecho y establecidas para regular la coexistencia de esas comunidades independientes o para la persecución de objetivos comunes. Los límites de la independencia de los Estados, entonces, no se presumen. Así, la limitación primordial que impone el derecho internacional al Estado es la exclusión –salvo que exista una regla contraria que lo permita– de todo ejercicio de su poder en el territorio de otro Estado⁵⁷.

La consecuencia de este paradigma es un derecho internacional de carácter *general* y ya no particular (compuesto por normas que pretenden ser válidas para todos los sujetos de lo que pasa a concebirse como "comunidad internacional") en el que no se reconoce a nadie ni nada por encima del propio conjunto de Estados pares. Se trata, entonces, de un derecho internacional en el que: (1) no existe órgano legislador diferenciado de quienes deben respetar la norma; (2) no hay órgano juzgador obligatorio que aplique el derecho internacional en caso de controversia (las jurisdicciones internacionales son siempre voluntarias, de modo que el Estado que no asiente no puede ser llevado ante un tribunal); (3) no hay poder de coerción contra los Estados ni mecanismos de enforcement (no existe ninguna fuerza de policía capaz de imponer el contenido de las normas del ordenamiento a los sujetos que lo integran). Lejos estamos, en este derecho internacional moderno, de la subordinación propia de los derechos internos.

Esta nueva conceptualización paratáctica del derecho internacional público, apoyada en la ficción de que los Estados son iguales jurídicamente por gozar de una soberanía exclusiva que no puede ser afectada por el resto de la comunidad internacional, recibe el espaldarazo doctrinario de una serie de pensadores que determinan las raíces teóricas de la disciplina⁵⁸. Entre ellos, el llamado "padre del derecho internacional" –el holandés Hugo Grocio (1583-1642)– estableció los cimientos de la disciplina al examinar la libertad de los mares (*De mare*

57 *S.S. Lotus* (Francia c. Turquía), CPJI, Fallo, 07/09/1927, CPJI Serie A, n.º 70, pp. 18-19 (traducción propia).
58 Sobre esto, puede leerse Kingsbury, Benedict y Straumann, Benjamin, "State of Nature versus Commercial Sociability as the Basis of International Law: Reflections on the Roman Foundations and Current Interpretations of the International Political and Legal Thought of Grotius, Hobbes, and Pufendorf", en *The Philosophy of International Law*, Besson, Samantha y Tasioulas, John (eds.), Oxford University Press, Oxford, pp. 33-51.

como no hay nada mas soberano que un estado, por def no se puede enforcear el derecho int publico

liberum, 1609) y el derecho de la guerra y la paz (*De iure belli ac pacis*, 1625) desde una perspectiva que justificaba la existencia de normas jurídicas comunes en un sustrato natural que convertía a los Estados en entes soberanos⁵⁹.

Los avances que, en los siglos siguientes, se producen en el ámbito europeo se sustentan en la concepción de una alianza de naciones que, a partir de acuerdos de paz, cooperan en torno de intereses compartidos que, sin embargo, dejan entrever ciertos impulsos imperiales. Es el caso de la Paz de Utrecht (1713-1715), que puso fin a la Guerra de Sucesión española e introdujo un nuevo equilibrio en la región a partir del poder creciente de Prusia, Rusia y Austria, creando las condiciones para la consagración del dominio de Gran Bretaña. El Tratado de París y el Congreso de Viena de 1815, que restablecieron el orden perdido tras la expansión imperialista de Napoleón, consagran la intención de celebrar reuniones de las principales potencias para tratar los "grandes intereses comunes" (art. 6 del Tratado)⁶⁰. Las críticas contra el Directorio Europeo que implicaba la Tetrarquía, en la que se aliaran Austria, Gran Bretaña, Prusia y Rusia (devenida luego Pentarquía con la inclusión de Francia), dieron lugar pronto al establecimiento de un "Concierto" europeo, en el cual se disimulaba el poder de los más poderosos bajo una serie de conferencias continentales en la que se procuraba una amplia intervención de los Estados de la región⁶¹. Del mismo modo, el control de los territorios coloniales generó —en teoría— un delicado equilibrio entre los Estados europeos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX,⁶² que, no obstante, discriminaba en la práctica diplomática a las poblaciones de los territorios bajo administración de las metrópolis⁶³.

Pero quizás para encontrar el ejemplo más claro de la consagración de la igualdad soberana de los Estados y la autotutela que implica un derecho internacional sin autoridad superior debamos esperar hasta principios del siglo XX, cuando, tras los desastres de la Primera Guerra Mundial, se instala por primera vez una organización interestatal política de carácter permanente.

La llamada *Sociedad de las Naciones* (o Liga de las Naciones, si preferimos traducir su denominación del inglés) fue creada por un acuerdo de voluntades (el Pacto), que encabezó el Tratado de Versalles de 1919. Su creación fue el resultado de un esfuerzo tendiente a establecer un régimen estatutario, con pretensiones de universalidad⁶⁴, destinado a preservar la paz y la seguridad y promover la cooperación internacional. Sin embargo, la Sociedad se fundaba no en la comunidad de Estados, sino en la sumatoria de los diversos miembros⁶⁵.

El fundamento paratático de la organización se percibe de modo claro en el hecho de que el Pacto fijó el principio de la seguridad colectiva (planteando que la guerra sería un asunto que concerniría a todos los miembros de la Sociedad y no solo a los beligerantes, art. 11) y estableció un sistema de toma de decisiones fundado en la unanimidad: "Las decisiones adoptadas en cualquier reunión de la Asamblea o del Consejo requerirán el acuerdo de todos los miembros de la Liga representados en la reunión, excepto cuando se hubiera determinado expresamente otra cosa en este Pacto o por los términos del presente tratado" (art. 6).

59 No podemos olvidar, sin embargo, que Grocio había ejercido de joven la abogacía en defensa de los intereses nacionales al representar a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Sobre su biografía y la importancia de sus obras, cfr. Haggnumacher, Peter, "Hugo Grotius (1583-1645)", en *The Oxford Handbook of the History of International Law*, op. cit., pp. 1098-1101. Sin embargo, es cierto que sus ideas sentaron las bases de un orden jurídico que, en el siglo XVII, fue propuesto para regular las relaciones entre Estados; cfr. Keene, Edward, *Beyond the Anarchical Society: Grotius, Colonialism, and Order in World Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

60 Uno de sus principales defectos fue, sin duda, la falta de creación de una estructura institucional; cfr. Simpson, Gerry, "International law in diplomatic history", art. cit., pp. 36-38.

61 Acerca del orden jurídico europeo como fundamento del derecho internacional clásico, Laghmani, Slim, *Histoire du droit des gens: du jus gentium impérial au jus publicum europaeum*, Pedone, París, 2008, pp. 117-222.

62 Cfr. Nuzio, Luigi, *Origini di una scienza: diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Vitterio Klostermann, Frankfurt-am-Main, 2012.

63 Becker Lorenz, Arnulf, "Universal International Law: Nineteenth-Century Histories of Imposition and Appropriation", *Harvard International Law Journal*, vol. 51 (2010), pp. 478-552.

64 Krüger, Peter, "From the Paris Peace Treaties to the End of the Second World War", en *The Oxford Handbook of the History of International Law*, op. cit., p. 884.

65 Gutiérrez Posse, Hortensia D.T., *Moderno derecho internacional y seguridad colectiva*, Zavalla, Buenos Aires, 1995, p. 82.

A pesar de las intenciones iniciales, la organización no logró sus objetivos. La voluntad de poder de las principales potencias aliadas y asociadas, la imposibilidad de uno de sus gestores —el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson— de lograr el ingreso de su país a la Sociedad, la exclusión inicial de Rusia y Alemania y un sistema de sanciones absolutamente descentralizado constituyeron serias deficiencias del sistema.

Tampoco el Pacto tuvo éxito en la prevención de la guerra. En su articulado no se preveía una prohibición del uso de la fuerza, sino simplemente una moratoria en el inicio de las hostilidades: las partes se habían comprometido a someter el asunto al arbitraje o a la encuesta del Consejo, convalidando en no recurrir en caso alguno a la guerra antes de los tres meses de haberse producido el fallo por los árbitros o el informe por el Consejo (art. 12). La imposibilidad, tanto jurídica como política, de evitar la ocupación japonesa de Manchuria en China y la anexión de Etiopía por parte de Italia precipitaron la caída de la Sociedad, y pusieron en crisis la idea de un derecho internacional poco flexible que no respondiera a las necesidades de la política. Los Estados que no estaban de acuerdo con el modo en que la Sociedad llevaba adelante las negociaciones y regulaba las relaciones interestatales abandonaron su membresía y dejaron de lado las obligaciones asumidas. Ya no había un ordenamiento institucional sólido capaz de impedir un nuevo enfrentamiento armado de proporciones universales.

3.4. El derecho internacional contemporáneo (desde 1945) y el sistema de las Naciones Unidas

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) —ejemplo último del debilitamiento sufrido por la Sociedad de Naciones—, los Estados vencedores convocaron a todos los países aliados, que habían estado en guerra contra las potencias del Eje, a una conferencia en San Francisco en la que se discutiría la creación de una nueva organización institucionalizada de la comunidad internacional con vocación universal: la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dado que hoy en día pensar en las normas jurídicas internacionales sin tener en cuenta el rol de las Naciones Unidas no resulta factible, consideramos que la instalación de la Organización ha significado un punto de inflexión que dio lugar a un nuevo modo de concebir la manera en que se regulan las relaciones entre los Estados: estamos en presencia de un derecho internacional contemporáneo con características particulares⁶⁶.

La firma de la Carta de la ONU en junio de 1945 instaló un ámbito político-jurídico destinado a mantener la paz y seguridad internacionales; fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y la cooperación internacional en la solución de problemas comunes (art. 1)⁶⁷. Para la consecución de estos propósitos, el tratado sentó una serie de principios, estructurados en torno del equilibrio jurídico entre los Estados, que ocupa el primer lugar en el artículo 2: "La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros". Asimismo, como corolario de la consagración de la soberanía como pilar de las relaciones internacionales, la Carta establece el principio de la no intervención en los asuntos internos de cada Estado (art. 2.7).

Es evidente, pues, que desde sus cimientos la ONU traduce una lógica asentada en una visión *westfaliana* del derecho internacional. Ese balance *inter pares* se descubre, con considerable influencia, en la composición de la Asamblea General —el órgano deliberativo de la Organización—, en la que todos los miembros de la ONU pueden participar (art. 9.1) y en la que cada uno de ellos tiene derecho a un voto (art. 18.1). Sin embargo —hay que decirlo— el régimen "democrático" creado por la Carta cuando da espacio a todos los miembros en una instancia de igualdad de derecho les otorga, en cambio, a las resoluciones de la Asamblea General un

66 Algunos autores, en cambio, señalan como origen del derecho internacional contemporáneo el Tratado de Versalles y la creación de la Sociedad de las Naciones; cfr. Preisner, Wolfgang, *Die Völkerrechtsgeschichte, ihre Aufgaben und ihre Methoden*, Steiner, Wiesbaden, 1984, p. 62; Rausan, Marie-Hélène, *Histoire du droit international public*, Ellipses, París, 2007, pp. 180-183.

67 El sistema creado por la Carta será estudiado, de manera mucho más profunda y sistematizada, en el capítulo 3 de esta obra. Aquí solo es cuestión de referirnos a las características generales del derecho internacional contemporáneo.

simple carácter no vinculante, que se limita a la posibilidad que tiene el órgano de "hacer recomendaciones" (art. 10).

En cambio, frente a una Asamblea paratáctica y sin muchas posibilidades de acción en términos concretos, el propio sistema instaura, como válvula de escape, un mecanismo por el cual las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial se reservan un ámbito de acción más amplio y más concreto, en el que tienen influencia directa en la toma de decisiones obligatorias para los Estados. En efecto, el Consejo de Seguridad —que es el órgano ejecutivo de la ONU y el responsable primordial del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales— no estará compuesto por todos los miembros de la ONU, sino integrado por quince miembros, de los cuales cinco ocupan su lugar de modo permanente (art. 23): se trata de los Estados Unidos, la República Popular China, la Unión Soviética (hoy Federación Rusa), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francia, es decir, los Estados aliados que vencieron a Alemania, Italia y Japón en 1945.

A diferencia de los otros diez miembros, que ocupan un asiento en el Consejo de modo transitorio, estos cinco miembros permanentes cuentan además con el llamado "derecho de veto", instrumento a través del cual cualquiera de ellos puede impedir que el Consejo de Seguridad tome decisiones, incluso cuando se cuente con el voto afirmativo de los otros catorce integrantes del órgano. A ello debe sumarse que, cuando nos referimos a las funciones del Consejo de Seguridad, no estamos en presencia de resoluciones carentes de importancia para la comunidad internacional: en efecto, el Consejo de Seguridad puede emitir meras recomendaciones (capítulo VI), pero puede —y he aquí su principal instrumento de acción— también tomar decisiones obligatorias (capítulo VII), que impliquen o no el uso de la fuerza contra un Estado.

La acción que el Consejo de Seguridad puede llevar adelante en el marco del artículo 42 de la Carta, que autoriza el empleo de la fuerza armada contra un Estado, ha llevado a numerosos doctrinarios a considerar que el tratado supone una delegación en dicho órgano de un derecho que los Estados pasan a prohibir para sí mismos: en efecto, el artículo 2.4 del mismo acuerdo establece que los miembros de la ONU "se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas". Esto es lo que algunas lecturas han denominado *cucisubordinación*, concepto que explica la centralización del uso de fuerza en el Consejo de Seguridad como un tercero⁶⁸.

En realidad, estimamos que, en rigor de verdad, la subordinación surgiría no tanto en la medida en que el Consejo puede actuar en contra de un Estado (oponiéndose a su voluntad, algo inusitado en el derecho internacional), sino más bien en la composición misma del Consejo, en la que algunos Estados tienen un poder relativo mayor para impulsar (u obstaculizar) la actuación del Consejo de acuerdo con sus propios intereses y conveniencias. Podría argumentarse que, en realidad, todo el esqueleto institucional creado por la ONU tiene como base la voluntad concurrente de los Estados que, manifestando su consentimiento, se han obligado por la Carta, pero también es cierto que dicho acuerdo universal ha sido preparado y presentado a la comunidad internacional por los pocos Estados que, triunfantes en la guerra, pretendían conseguir el apoyo universal para ocupar un lugar de privilegio en la discusión de los asuntos de incumbencia para todos.

En definitiva, el derecho internacional contemporáneo muestra, a través de la creación de las Naciones Unidas, un plano que responde, por un lado, al reconocimiento de la igualdad soberana de los Estados (que traduce la lógica westfaliana de la parataxis), manifestado esencialmente en el modo de acción de la Asamblea General, y —por otro— una marcada desigualdad entre aquellos Estados mejor posicionados para la negociación en 1945 y el resto, que se asienta en un funcionamiento del Consejo de Seguridad que responde más bien a una lógica hipotáctica. Este juego constante entre coordinación y subordinación, entre parataxis e hipotaxis, es característico, entonces, del sistema de contrapesos creados por la Carta de las Naciones Unidas y resulta una de las propiedades más evidentes del derecho internacional contemporáneo.

68 Gutiérrez Posse, Hortensia D.T., op. cit., pp. 285-292.

A la luz de estos razonamientos, restaría preguntarnos si no es posible pensar que toda la historia del derecho internacional, desde su concepción preclásica hasta la actualidad, no ha encontrado sustento en la alternancia entre las pretensiones políticas de los Estados más poderosos y el intento por asegurar la participación equilibrada de todos. No resulta difícil, por un lado, encontrar en el derecho interestatal antiguo, claramente hipotático, instrumentos convencionales que disimulaban esa desigualdad con cláusulas equitativas (puede pensarse en los tratados *inter pares* —llamados *foedera aequa*— que Roma "invitaba" a suscribir a las ciudades-Estado que tenía intenciones de controlar). Por otro lado, en la Edad Moderna la consagración de la igualdad jurídica de los Estados en muchas ocasiones oculta claras diferencias en las capacidades de negociación de las monarquías europeas. Sin embargo, lo que resulta novedoso en el derecho internacional contemporáneo a la luz de la Carta de la ONU es, pues, el explícito reconocimiento de un sistema fundado simultáneamente en criterios hipotáticos y paratáticos.

4. Objeto del derecho internacional: expansión y fragmentación

En el transcurso de su desarrollo, desde sus primeras manifestaciones, la comunidad de Estados fue permitiendo una progresiva ampliación de las temáticas sometidas a negociación en el plano internacional. Así, una lectura de los tratados preservados del período preclásico, tanto en la Antigüedad como en la Edad Media, permite advertir que en gran medida las normas interestatales que se acordaban implicaban solo un mínimo de compromiso y se limitaban únicamente a aquellas áreas en las que era preciso preservar la integridad nacional o defender la seguridad doméstica frente a los otros. Así, estos instrumentos se relacionaban con la guerra (siendo habituales las alianzas militares de tipo ofensivo y defensivo, así como los tratados de paz que daban final a las hostilidades) y con la fijación de las fronteras territoriales (solución de disputas limítrofes). Unos pocos textos se ocupaban de aspectos relacionados con el comercio bilateral. Con la universalización del derecho internacional clásico que se experimenta desde la Edad Moderna, los asuntos que pasaron a ser objeto de la disciplina se multiplicaron significativamente.

A partir de mediados del siglo XIX, con la creciente complejidad de las relaciones internacionales, el derecho que regía los vínculos entre Estados se extendió hasta cubrir temáticas que, hasta ese momento, habían quedado relegadas al ordenamiento interno. Si bien muchos comenzaron a hablar de una pérdida de soberanía como contrapartida del desarrollo del derecho internacional⁶⁹, lo cierto es que el avance de la normativa siempre encontró fundamento en la voluntad común de los Estados que estaban dispuestos —según sus propios intereses— a obligarse frente a los otros. En el cambio de siglo presenciamos una considerable expansión en las esferas técnicas de cooperación (se crea la Unión Postal Universal en 1874), de las regulaciones humanitarias (se firma la Declaración de San Petersburgo que prohíbe el empleo de ciertas armas nocivas en 1868), del régimen de administración colonial (Tratado de Berlín de 1885) y del derecho aplicable al uso de la fuerza y a la conducción de hostilidades (Conferencias de La Haya de 1899 y 1907)⁷⁰, para mencionar algunos de los ejemplos más relevantes.

Con la instauración de las Naciones Unidas como foro de negociación entre sus miembros, se ha fomentado la discusión jurídica sobre temas que, hasta ese momento, no habían sido regulados de modo preciso (derechos humanos, derecho ambiental, derecho internacional penal, derecho comercial internacional, derecho del espacio ultraterrestre, etc.) o que habían dependido de normas consuetudinarias no siempre reconocidas abiertamente por los Estados. En este último caso, la labor de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) ha permitido que, mediante la codificación, se aprobaran textos convencionales basados en obligaciones establecidas por vía de la costumbre, en áreas como el derecho del mar, las relaciones diplomáticas y

69 En este sentido, soberanía como fuerza interior y derecho internacional como fuerza exterior parecen contradecirse; Janis, Mark W., "Sovereignty and International Law: Hobbes and Grotius", en *Essays in Honour of Wang Tieya*, MacDonald, Ronald S.J. (ed.), Kluwer Academic Publishers y Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp. 391-400.

70 Simpson, Gerry, "International law in diplomatic history", art. cit., pp. 36-37.

consulares, la sucesión de Estados, el derecho de los tratados, entre otros. En la actualidad, a este complejo abanico temático se suma la frecuente intervención en el ámbito internacional de nuevos actores no estatales (desde los grupos terroristas hasta las organizaciones no gubernamentales⁷¹, para marcar la extensión del espectro) que le dan un nuevo perfil al derecho internacional y a su agenda actual⁷².

La expansión del derecho internacional no solo se ha producido en términos de reglas vigentes, sino también en lo que se refiere a la proliferación de órganos e instancias internacionales a la que los Estados pueden recurrir en caso de desearlo. La ONU ha convertido el derecho internacional en un área que, para muchos, ha devenido extremadamente técnica y cuyo control y seguimiento se ha burocratizado en demasía. Este fenómeno ha dado lugar a cierta inquietud respecto de lo que se ha llamado fragmentación (tanto sustancial como institucional) del derecho internacional, que con su excesiva singularización y multiplicidad de subregímenes y subramas ha perdido en parte su tradicional carácter unitario u holístico⁷³. En el marco de la CDI, se ha elaborado un informe especial sobre el problema⁷⁴ que propone una interpretación sistemática de la normativa internacional que permita sortear los inconvenientes derivados de la existencia cada vez más habitual de ordenamientos específicos semiautónomos o autocontenidos⁷⁵. De este modo, se asegura que los principios propios del derecho internacional público general se mantengan en la interpretación de cualquier rama especializada, preservando así la unidad del sistema en su conjunto.

5. Fundamentos, validez y observancia del derecho internacional

Si bien parece claro que el derecho internacional surge fácticamente de la necesidad de los Estados de regular sus conductas mutuas e interacciones (y desde ese lugar habría poco que explicar)⁷⁶, lo cierto es que podemos relevar al menos dos corrientes críticas que se han ocupado de plantear y discutir los fundamentos del derecho internacional público en su dimensión descentralizada, horizontal y paratáctica.

Por un lado, se distingue la llamada corriente voluntarista, que aún a quienes sostienen que este ordenamiento se explica esencialmente por la voluntad del Estado; ello ocurre o bien porque se entiende que hay una autolimitación en la medida en que cada Estado manifiesta

discrecionalmente su consentimiento ante los otros (G. Jellinek⁷⁷), o bien porque se funda en la consolidación de una voluntad común (*Vereinbarung*) que surge de la coincidencia y fusión de las voluntades individuales concurrentes de los Estados (H. Triepel⁷⁸). También se ha sostenido que la comunión de voluntades supone la imposición de requerimientos formales fundados en el principio de que los acuerdos deben ser cumplidos (positivismo de D. Anzilotti⁷⁹).

Por el otro lado, se encuentran los partidarios de la corriente objetivista, que manifiestan que el derecho internacional encuentra su razón de ser en consideraciones independientes de la decisión estatal. Para algunos de ellos la obligatoriedad de sus normas se debe a la presencia de valores naturales que el derecho recoge por vía divina (teoría iusnaturalista de S. Pufendorf⁸⁰) o por convicciones jurídicas coexistentes (iusnaturalismo racional de A. Verdross⁸¹); un segundo grupo de juristas, en cambio, explica su carácter obligatorio por la existencia de una norma fundamental de la que deriva toda la regulación (teoría normativista de H. Kelsen), mientras que un tercer conjunto de autores lo atribuye al reconocimiento de que son los hechos sociales los que condicionan y dan forma a la dimensión jurídica (teorías sociológicas de G. Scelle⁸² y N. Politis⁸³).

Sea cual fuere el sustento teórico que caracteriza las bases del derecho internacional, cabría preguntarse por la eficiencia de un sistema en el que los Estados mismos (que son los que han de cumplir con sus preceptos) crean las normas por las que se van a obligar y se reservan el derecho de aceptar o no los mecanismos de solución de controversias (que, por otra parte, ellos mismos han elaborado). En efecto, mucho se ha dicho respecto del carácter endeble de un sistema normativo en el que los sujetos pueden elegir cumplir con aquellas normas que los favorecen y dejar de lado las que consideran repugnantes o simplemente inconvenientes. Sin embargo, es preciso señalar el grado alto de respeto que los Estados manifiestan con relación a los acuerdos y costumbres de los que forman parte. En una célebre frase, Louis Henkin afirmaba que "casi todas las naciones observan casi todos los principios del derecho internacional y casi todas las obligaciones casi todo el tiempo"⁸⁴. Ello puede explicarse por motivos que, en gran medida, exceden el dominio de lo jurídico.

Algunos autores se han preguntado acerca de cuáles son las ventajas del derecho internacional y, en consecuencia, qué es lo que lleva a los Estados a observar sus normas. Así, por caso, en el derecho internacional antiguo la religión era un elemento fundamental para asegurar la observancia de los acuerdos, puesto que se creía que toda violación ocasionaba la ira de los dioses y engendraba males para la propia comunidad. En una época como la actual, en cambio, numerosos Estados cumplen con sus obligaciones internacionales por consideraciones de política exterior (ej., con la expectativa de reciprocidad, ciertos Estados deciden limitar su soberanía solamente en pos de lograr que otros hagan lo mismo), de política interna (ej., autoridades que toman decisiones teniendo en cuenta eventuales resultados electorales) o económicas (ej., la posibilidad de recibir inversiones extranjeras). Todas estas consideraciones, de tipo metajurídico, se suman a una serie de circunstancias psicológicas que hacen que los Estados se comprometan a obligarse por las normas internacionales.

En definitiva, en tiempos en que la opinión pública y la sociedad civil han encontrado mecanismos para dejar al descubierto conductas estatales inapropiadas, y en que la seguridad jurídica genera confianza en los otros, no es recomendable ser tenido por un infractor de las normas del derecho internacional frente al resto de la comunidad de Estados. Quizás este

71 Lynch, Cecilia, "Peace Movements, Civil Society, and the Development of International Law", en *The Oxford Handbook of the History of International Law*, op. cit., pp. 198-221.

72 La escuela de New Haven (Yale) sobre derecho internacional intenta dar cuenta de estas nuevas características, ocupándose no tanto de las normas cuanto de los complejos procesos internacionales en los que intervienen un sinnúmero de participantes además de los Estados. Para una síntesis de las ideas de esta escuela, principalmente de las aportaciones de W. Michael Reisman, cfr. Boyle, Alan y Chinkin, Christine, *The Making of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 12-14.

73 Shaw, Malcolm N., *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 6.ª edic., 2008, pp. 65-66.

74 Comisión de Derecho Internacional, "Informe de la Comisión de Derecho Internacional", 68.º período de sesiones (01/08 al 09/08/2006 y 09/07 al 11/08/2006), Asamblea General, Documentos Oficiales, 61.º período de sesiones, Suplemento n.º 10 (A/61/10), capítulo xii, «Fragmentación del Derecho Internacional: dificultades derivadas de la diversificación y expansión del derecho internacional», Conclusiones del Grupo de Estudio, disponible en <http://untreaty.un.org/ilc/reports/2006/2006report.htm>.

75 Acerca de la fragmentación del derecho internacional, puede consultarse Abi-Saab, Georges, "Fragmentation or unification: some concluding remarks", *New York University Journal of International Law and Politics*, vol. 31 (1999), pp. 919-938; Benvenisti, Eyal y Downs, George W., "The empire's new clothes: political economy and the fragmentation of international law", *Stanford Law Review*, vol. 60 (2007), pp. 895-931; Hafner, Gerhard, "Pros and Cons Ensnaring From Fragmentation of International Law", *Michigan Journal of International Law*, vol. 25 (2004), pp. 849-888; Koskeniemi, Martti y Leino, Päivi, "Fragmentation of International Law: Postmodern anxieties", *Leiden Journal of International Law*, vol. 16 (2002), pp. 653-679; Pauwelyn, Joost, "Fragmentation of International Law" (2008), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, disponible en: <http://www.mpepil.com>; Prost, Mario, *The Concept of Unity in Public International Law*, Hart Publishing, Oxford, 2012; Shany, Yuval, *The competing jurisdictions of international courts and tribunals*, Oxford University Press, Oxford, 2008; Young, Margaret (ed.), *Regime Interaction in International Law. Facing Fragmentation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

76 De hecho, la comunidad internacional —como todo grupo social— requiere de un derecho que produzca órdenes que se imponen a sus integrantes; cfr. Sinagra, Augusto y Bargiacchi, Paolo, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Giuffrè, Milán, 2009, p. 1.

77 Jellinek, Georg, *Allgemeine Staatslehre*, Häring, Berlín, 1914 (traducción castellana: *Teoría general del Estado*, Albatros, Buenos Aires, 1954).

78 Triepel, Heinrich, *Völkerrecht und Landesrecht*, Hirschfeld, Leipzig, 1899.

79 Anzilotti, Dionisio, *Corso di diritto internazionale*, vol. I: "Introduzione e teorie generali", Athenaeum, Roma, 8.ª edic., 1928.

80 Pufendorf, Samuel, *De jure naturae et gentium libri octo*, Lund, 1672 (edición inglesa: Clarendon Press, Oxford, 1951).

81 Verdross, Alfred, *Völkerrecht (Rechts- und Staatswissenschaften)*, vol. 10, Springer, Viena, 5.ª edic., 1964, (traducción castellana: *Derecho Internacional Público*, Aguilar, Madrid, 1961).

82 Scelle, Georges, *Précis de droit de gens*, Sirey, París, 1932.

83 Politis, Nicolas, *Les nouvelles tendances du droit international*, Hachette, París, 1927.

84 Henkin, Louis, *How Nations Behave: Law and Foreign Policy*, Columbia University Press for the Council on Foreign Relations, Nueva York, 1979, p. 47.

último aspecto explique por qué los Estados más poderosos, que claramente podrían en la práctica ignorar el derecho internacional amparándose en la ausencia de modos de ejecución, intentan explicar sus comportamientos reinterpretando el derecho vigente (ej., mediante nuevas instituciones y doctrinas justificatorias como la legítima defensa preventiva, la intervención humanitaria, la responsabilidad de proteger, para señalar solo algunas de las más recientes), pero nunca reconociendo la comisión de actos violatorios de sus normas. En este contexto, la discusión actual ya no parece girar en torno del fundamento del derecho internacional, sino que, más bien, se refiere a la pretensión, por parte de los Estados con mayor autoridad política, de encontrar espacios de *legitimación* para sus propias conductas ante los terceros⁸⁵.

Esta historia conservadora del derecho internacional ha generado un movimiento revisionista contrario en la doctrina más reciente, que procura reivindicar los espacios polémicos de una visión periférica de las relaciones internacionales⁸⁶. Según estas nuevas lecturas, el derecho internacional resulta un instrumento de poder y un discurso efectivo que se adapta a los diversos intereses⁸⁷. En tiempos globalizados, la respuesta a ese derecho concebido en términos de ventajas unilaterales se encuentra, quizás, en una mayor democratización de las instituciones internacionales⁸⁸.

De las lecturas más críticas del fenómeno se infiere otra de las ventajas de un derecho internacional común a todos: la fijación de una terminología compartida que genera un espacio de comunicación adecuado entre los Estados⁸⁹. Ese lenguaje común proporciona los medios apropiados para que los Estados puedan anunciar sus intenciones, brinda certidumbre mutua sobre sus políticas futuras, establece con precisión la naturaleza de los acuerdos –incluyendo sus límites y condicionantes– y cubre a estos de solemnidades, de modo de crear expectativas sobre su estabilidad⁹⁰. Cabe decir que el éxito de un vocabulario uniforme, no obstante, se debe paradójicamente al hecho de que muchos de los términos principales del derecho internacional, de modo consciente, no son definidos por los Estados en los instrumentos respectivos (pensemos en expresiones como “uso de fuerza” o “conflicto armado”, recurrentes en los tratados,

que no tienen un contenido único): esto brinda un considerable espacio de acción a la interpretación individual que pueda hacer de la norma cada uno de los sujetos estatales.

El derecho internacional supone una narrativa y una retórica extremadamente útiles para describir y justificar las acciones de los Estados⁹¹ y, desde ese lugar, pareciera no contraponerse, sino reforzar la hegemonía imperial que históricamente ha signado las relaciones internacionales⁹². Pero esta “concretitud” –el hecho de que responda a los intereses políticos y económicos de los actores del sistema internacional– es balanceada por una tendencia complementaria, una abstracción de “normatividad”, que hace que el derecho internacional *deba* tener cierta impronta que lo convierta en una disciplina autónoma y se ocupe de ampliar sus contenidos sin recurrir de modo permanente a la realidad específica de los intereses coyunturales de los Estados. Esta oposición, pero a la vez comunión, entre las pretensiones concretas y normativas que caracterizan al derecho internacional es lo que M. Koskenniemi ha descrito como la confluencia de una *apología* y una *utopía*, respectivamente⁹³. Se trata del cruce entre un sistema normativo creado para justificar el accionar puntual de los Estados (aspecto sociológico-político) y un orden fundado en el desarrollo doctrinario de conceptos más abstractos como “paz”, “seguridad internacional”, “medio ambiente sano”, entre otros (aspecto filosófico). En rigor de verdad, se trata de la contraposición simultánea entre un modelo tradicional grociano –en el que la comunidad internacional se funda en los Estados, que colaboran entre sí pero con sus propios intereses en miras– y un modelo moderno kantiano –en el que se procura la solidaridad transnacional no tanto entre Estados, sino para la humanidad, que se configura como el gran sujeto internacional–⁹⁴.

Pareciera tratarse de visiones incompatibles en torno a la naturaleza del derecho internacional y, sin embargo, resultan perspectivas interdependientes. En el seno de esta naturaleza única, en un delicado equilibrio entre el realismo y el idealismo, se establece nuestra disciplina. He allí la riqueza teórica de su concepción y el desafío que implica estudiarla. El derecho internacional es, y ha sido siempre, una construcción jurídica *sui generis*: en ello radica, precisamente, una de las posibles explicaciones para sus logros e inconsistencias. Este carácter particular representa –sin dudas– un motivo apasionante para encarar su estudio.

- 85 Acerca de la crisis de legitimidad del derecho internacional –provocada en muchos casos por interpretaciones forzadas de las normas o por la búsqueda de excepciones para explicar el incumplimiento de las reglas–, cfr. Charlesworth, Hilary y Coicaud, Jean-Marie (eds.), *Fault Lines of International Legitimacy*, Cambridge University Press and United Nations University, 2010, y Buchanan, Allen, “The Legitimacy of International Law”, en *The Philosophy of International Law*, op. cit., pp. 79-96 y la respuesta, en el mismo volumen, de Tasoulas en pp. 97-116.
- 86 Ver, por ejemplo, Rajagopal, Balakrishnan, *International Law from Below*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003; Orford, Anne, *International Authority and the Responsibility to Protect*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011. Entre los teóricos del así llamado movimiento TWAIL (Third World Approaches to International Law), puede incluirse también a Chimni, B.S., “Legitimizing the international rule of law”, en *The Cambridge Companion to International Law*, op. cit., pp. 290-308. Estas teorías “marginales” y novedosas sobre el derecho internacional, que no complementan los avances previos, sino que los ponen en duda, han sido rechazadas por autores como Müllerson, Rein, *Ordering Anarchy: International Law in International Society*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2000, pp. 66-67, por considerar que no contribuyen al desarrollo central (mainstream) de la disciplina.
- 87 Douzinas, Costas, *Human Rights and Empire: the Political Philosophy of Cosmopolitanism*, Routledge & Cavendish, Abingdon y Nueva York, 2007. Desde una visión marxista, llega a la misma conclusión Zolo, Danilo, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Laterza, Roma-Bari, 2006 (edición castellana: *La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad*, Trotta, Madrid, 2007), para quien el derecho internacional es un instrumento de poder de los más poderosos. Las lecturas feministas del derecho internacional tienden a ver en este orden normativo la materialización de un régimen patriarcal en el que los Estados más poderosos se ven masculinizados y se imponen activamente a las naciones más débiles que –feminizadas– se ven conquistadas y dominadas; cfr. Charlesworth, Hilary y Chinkin, Christine, *The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis*, University Press, Manchester, 2000. Acerca de Estados Unidos, su voluntad “imperial” y su manipulación del derecho internacional, ver Saito, Natsu T., *Meeting the Enemy. American Exceptionalism and International Law*, New York University Press, Nueva York y Londres, 2010.
- 88 Condorelli, Luigi y Cassese, Antonio, “Is Leviathan Still Holding Sway over International Dealings?”, en *Realizing Utopia. The Future of International Law*, Cassese, Antonio (ed.), Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 24-25. Para una postura más revolucionaria que propugna reaccionar frente a la indignación moral que provoca el derecho internacional actual y sus desigualdades manifestadas, cfr. Allott, Philip, “International Law and International Revolution. Reconciling the World”, en *The Health of Nations. Society and Law Beyond the State*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 399-422.
- 89 Shaw, Malcolm N., op. cit., p. 7.
- 90 Bull, Hedley, op. cit., p. 142.

- 91 Goldsmith, Jack L. y Posner, Eric A., *The Limits of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 167-172.
- 92 Asi, W.G. Grewa encara su célebre estudio histórico del derecho internacional moderno (*Epochen der Völkerrechtsgeschichte*, Nomos, Baden-Baden, 1984) identificando periodos históricos que se instalan sobre distintos momentos hegemónicos: una era española (1494-1648), una era francesa (1648-1815) y una era británica (1815-1919). Estas tres etapas representan los picos de las expansiones imperialistas nacionales. Sobre el tema, cfr. Cohen, Jean L., “Whose Sovereignty? Empire vs. International Law”, *Ethics & International Affairs*, vol. 18, n.º 3, (2004), pp. 1-24.
- 93 Koskenniemi, Martti, *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
- 94 En su obra *Sobre la Paz Perpetua (Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf)* de 1795, Immanuel Kant confiaba en que, mientras no hubiese posibilidad de establecer un “Estado mundial”, la civilización debía fomentarse para que eventualmente pudiera surgir una federación universal de repúblicas. Ver, al respecto, Koskenniemi, Martti, “International law in the world of ideas”, en *The Cambridge Companion to International Law*, op. cit., p. 53. Acerca de la influencia kantiana en filósofos posteriores del derecho internacional –tales como Rawls o Habermas–, puede consultarse Perreau-Saussine, Amanda, “Immanuel Kant on International Law”, en *The Philosophy of International Law*, op. cit., pp. 53-75.